

EU의회의 인공지능법안의 주요 내용에 관한 소고*

— EU집행이사회의 인공지능법안과 비교해서 —

金 重 權**

<국문초록>

EU회원국 전원이 EU의회가 마련한 인공지능법안을 승인함에 따라(2024.2.2.) 조만간 EU인공지능법이 현실화된다. 오늘날 고전적 영토국가의 모습은 강하게 씻겨지고 있다. 공법이 자신의 국내 영토적 한계를 넘어섰다는 것에서 공법의 탈영토주의화(Entterritorialisierung des Öffentlichen Rechts)는 새삼스럽지 않으며, 개별국가를 넘는 문제를 다루도록 구상된 글로벌 공법의 등장 역시 자연스럽다. EU의회는 기본적으로 EU집행이사회의 2021.4.21.에 마련한 EU인공지능법안(이하에서 ‘이사회법안’으로 표기함)을 바탕으로 리스크 기반의 인간중심적 착안점을 원칙적으로 유지하면서, 관련 위원회에서 집중적인 협의한 사항과 이사회법안에 대해 제기된 다양한 비판을 적극적으로 수용하여 이사회법안의 주요 내용을 다수 변경하고 새로운 사항을 추가하였다. 이사회법안과 비교해서 의회법안의 주요 내용은 다음과 같다: 의회법안은 제1조에서 인공지능법의 목표로 인간중심적이고 신뢰할만한 인공지능의 도입을 분명히 언급하였다. 의회법안은 인공지능시스템에 관해 자율개념(Autonomiebegriff)을 추가하여 새로이 개념정의의 함으로써, 사물적 적용영역과 관련해서 이사회법안과 비교해서 새로운 중요한 변화를 강구하였고, 인공지능의 제공자와 운영자도 인적 규율대상으로 추가하였다. 반면 오픈소스 소프트웨어(OSS)는 명백히 적용영역에서 제외된다. 의회법안은 이사회법안과 마찬가지로 기본적인 리스크기반의 착안점을 견지하여, 리스크 및 그로 인한 규율수준을 기왕의 3가지(수용불가능한 리스크의 인공지능시스템, 高리스크의 인공지능시스템, 低리스크의 인공지능시스템)에 새로운 리스크등급의 하나로 기본모델을 추가로 설정하였는데, 여기에는 가령 ChatGPT와 같은 생성형 인공지능모델(generative KI Modelle)이 들어간다. 개별적 결정 발견의 설명에 관한 권리가 명문화된 것(의회법안 제68조의c)처럼, 이사회법안보다 인공지능시스템의 투명성과 설명가능성이 제고되었다. 학문의 자유에 대해 이사회법안보다 더 광범하게 특권이 부여되었고(의회법안 제2조 제5항의d), 사회적으로 생태적으로 유익한 결과를 뒷

* 이 논문은 2017년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2017 S1A6A3A01078538).

** 중앙대학교 법학전문대학원 교수

받침하기 위한 인공지능시스템의 연구·개발의 증진이 강구되었다(의회법안 제54조의a). 조작 인공지능시스템의 금지와 관련해서 의회법안은 몇 가지 중요한 보완을 담고 있는데, 특히 사용기술의 목표 및 효과와 관련한 중요한 변경을 제안하였다(의회법안 제5조 제1항 제a호). 감정인식시스템의 경우 이사회법안에서는 형사소추 등의 분야에서 그것의 사용만이 고리스크의 인공지능으로 분류되었지만, 의회법안에서는 출시(유통)·운전·사용이 금지된다. EU인공지능법은 인공지능시스템에 관한 글로벌 스탠다드이기에, 우리 법제의 형성 역시 동법의 주요 내용으로부터 완전히 자유로울 수 없다. EU인공지능법의 제정을 계기로 우리 인공지능법 역시 인간중심적이고 신뢰할만한 인공지능의 도입을 전제로, 사익·공익의 보호와 기술의 혁신이 균형 있게 강구되어야 한다.

주제어: 공법의 탈영토주의화, 글로벌행정법, EU의회의 인공지능법안, EU집행이사회의 인공지능법안, 인공지능시스템, 기본모델, 생성형 인공지능모델

목 차

- I. 처음에-글로벌 스탠다드가 될 수 있는 EU인공지능법의 출현
- II. 입법목표의 명문화
- III. 인공지능법의 적용영역의 변화
- IV. 리스크의 등급과 관련한 변경
- V. 인공지능기반의 결정의 불투명성을 제고하기 위한 변경
- VI. 연구특권의 분야에서의 변경
- VII. 조작 인공지능시스템 관련한 변경
- VIII. 감정인식시스템과 관련한 변경
- IX. 맺으면서-법익의 보호와 혁신의 증진 사이에 균형을 잡는 입법

I. 처음에-글로벌 스탠다드가 될 수 있는 EU인공지능법의 출현

EU의회와 EU각료이사회가¹⁾ 참여한 EU입법절차인 3부절차(Trilogverfahren) 끝에 지난 2023.12.8.-9.에 인공지능법(KI-Gesetz, Verordnung)의 제정에²⁾ 대해 정치적으로 의견

1) EU각료이사회(Rat der Europäischen Union: Rat)는 유럽이사회(Europäischer Rat; European Council)와는 구별된다. 유럽이사회는 ‘EU정상회의’나 ‘유럽수뇌이사회’라고도 하는데, EU의 각 회원국의 정상들의 회의체이다. 입법권을 갖지 않으며, EU의 입법에도 참여하지 않지만, 입법의 방향 등을 제시하거나 각 회원국간의 타협을 발견한다든지 향후 EU의 발전을 위한 계기를 마련한다든지 하는 상위기관으로서의 나름의 역할을 한다.

2) EU기관은 제1차법인 여러 EU조약에 의거하여 제2차법에 해당하는 법적 행위를 하는데, 이

일치를 보았고, 드디어 2024.2.2.에 EU의 회원국 전원이 EU의회가 지난 6.14.에 마련한 법안(이하에서 ‘의회법안’으로 표기함)을³⁾ 승인하였다. 인공지능을 위한 전세계적인 포괄적인 규정집으로서의 EU인공지능법은 인공지능시스템에 관한 글로벌 스탠다드가 될 수 있기에, 우리 법제의 형성 역시 동법의 주요 내용으로부터 완전히 자유로울 수 없다.⁴⁾ 의회법안은 기본적으로 EU집행이사회(Europäische Kommission)가 2021.4.21.에 마련한 EU인공지능법(명령)안(이하에서 ‘이사회법안’으로 표기함)을⁵⁾ 바탕으로 리스크 기반의 인간중심적 착안점을 원칙적으로 유지하면서, 관련 위원회에서⁶⁾ 집중적인 협의한 사항과 이사회법안에 대해 제기된 다양한 비판을 적극적으로 수용하여 이사회법안의 주요 내용이 다수 변경되고 새로운 사항이 추가되었다. 특히 불온한 ‘파우스트의 계약’으로 여겨질 법한 생성형 인공지능(generative KI) 애플리케이션의 출현에 대응하여, 의회법안은 그것이 포함될 수 있는 기본모델(Basismodelle; foundation models)을 새로운 리스크의 범주로 도입하였다.

제도적 표준에 해당하는 인공지능법제는 기본권적 측면에 못지않게 산업적 측면에서 엄청난 영향을 미치기에, 글로벌 스탠다드 법제의 마련은 인공지능 패권에 연결된다.⁷⁾

에 해당하는 법적 행위가 EU운영조약 제288조는 EU명령(Verordnung), EU지침(Richtlinie), EU결정(Beschluss), EU권고(Empfehlungen) 그리고 EU견해표명(Stellungnahmen)이다. 이들을 우리 법상황과 비교하면 EU명령은 형식적 법률, EU지침은 (독일에서의) 대강적 법률, 결정은 행정행위, 권고는 행정지도, 견해표명은 교시와 같은 비공식적 행위에 해당할 수 있다. 많은 문헌들이 EU명령(Verordnung, Regulation)이를 ‘규정’이나 ‘규칙’으로 옮기는데, 그것은 공법학에서의 용례와는 맞지 않는다. EU명령은 법률처럼 EU회원국에 대해 직접적 구속력을 발생하므로 오해를 불식하고 이해를 증진하기 위해 법률로 명명하는 것이 좋을 듯하다. EU의 문헌에서도 ‘EU인공지능명령’을 영어판으로는 ‘인공지능법’(Artificial Intelligence Act)의 이름을 붙였다. 상론: 김중권, EU행정법, 2018, 90면 이하.

3) Europäisches Parlament, Gesetz über künstliche Intelligenz, 14.06.2023, P9_TA(2023)0236, 찬성 499표, 반대 28표, 기권 93표로 통과됐다.

4) 글로벌 스탠다드인 EU인공지능법의 출현을 계기로, 행정법을 국내법의 차원에서 바라보는 기왕의 인식에서 벗어나 공법의 탈영토화에 부응한 국제적 행정법에 관한 관심이 제고될 필요가 있다. 상론: 김중권, 공법의 탈속지주의화에 따른 국제적 행정법에 관한 연구, 공법연구 제49집 제1호(2020.10.31.). ; 이창휘, 국제행정법의 개념 및 기능에 대한 일 고찰, 공법연구 제31집 제2호(2002); 류병운, 세계행정법, 행정법연구 제16호(2006.10); 김대인, 세계행정법과 국제기구, 행정법연구 제45호(2016); 김성원, WTO 체제의 유효성에 관한 세계행정법 시각에서의 검토, 동아법학 제64호(2014.8).

5) 정식의 명칭은 ‘인공지능을 위한 일치된(조화된) 규율에 대한 명령안’(Verordnungsentwurf zu harmonisierten Regelungen für die künstliche Intelligenz)이다.

6) 주도적 역할을 ‘역내시장과 소비자보호를 위한 위원회’(IMCO)와 ‘시민의 자유, 정의와 내무를 위한 위원회’(LIBE)가 하고 다른 위원회들은 이들 위원회의 의견을 그대로 따랐다.

7) 최근의 바이든 미국 행정부는 2023.10.30.에 인공지능규제 행정명령(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)을 공포하였다. 각국의 입법동향에 관해서는 참고문헌: 「2023 국내외 AI 규제 및 정책동향 LAWnB IP Exclusive Report」, 톰슨로이터코리아); 「바이든 행정부의 첫 인공지능(AI) 행정명령과 시사점」

당연히 제 국가들은 그것에서 자국의 산업경쟁력의 비교우위를 여하히 확보할 것이냐가 관건이다. 인공지능 분야에서 선도적 위치를 차지하기 위해 비단 EU만이 아니라 미국을 포함한 각국의 법제에서 시사점을 적극적으로 찾아야 하는데, 조만간 EU인공지능법이 출현할 것이므로, 우리의 입법에 시사점을 모색하는 차원에서 이사회법안에 관한 기왕의 연구를 바탕으로,⁸⁾ 이사회법안과 의회법안의 비교에 초점을 맞춰 의회법안에서 변경되거나 추가된 주요 내용을 검토하고자 한다.⁹⁾

II. 입법목표의 명문화

이사회법안은 규율의 핵심목표로 인간중심적이고 신뢰할만한 인공지능의 증진을 내세웠지만 이를 단지 ‘제안이유(Erwägung)-1’에서만 언급하고, 입법목적에서 직접 언급하지 않았다.¹⁰⁾ 그러나 의회법안은 목적조항으로서의 제1조에서 인공지능법의 목표가 인간중심적이고 신뢰할만한 인공지능의 도입임을 분명히 하였다.¹¹⁾ 동 법안 제1조가 보여주듯이, 의회법안은 이사회법안에서 이미 명문으로 언급된 건강, 안전 그리고 기본권과 같은 보호대상 말고도 민주주의, 법치국가적 상태와 환경과 같은 집단적 보호대상도 인공지능시스템(KI-System)으로 인한 유해한 영향으로부터 보호하는 것을 천명하고, 아울러 혁신의 증진도 목표로 한다. 즉, 의회법안은 인공지능법의 목표를 다음의

(이슈브리프 제480호, 2023.11.10., 국가안보전략원).

- 8) 김중권, EU인공지능명령안의 주요 내용과 그 시사점, 헌법재판연구 제8권 제2호, 2021.12.31. 65면 이하. 참고문헌: 박해성/김법연/권현영, 인공지능 규제에 대한 연구-유럽연합의 입법안을 중심으로-, 공법연구 제49집 제3호, 2021, 349면 이하; 이수환/박소영, 금융분야 AI 가이드라인 도입 추진과 시사점, 국회입법조사처 이슈와 논점 제1878호, 2021.10.12.
- 9) 참고문헌: Feuerstack/Becker/Hertz, Die Entwürfe des EU-Parlaments und der EU-Kommission für eine KI-Verordnung im Vergleich, ZfDR 2023, 421ff.; Becker/Feuerstack, Der neue Entwurf des EU-Parlaments für eine KI-Verordnung, MMR 2024, 22ff.
- 10) 우리 입법에서 뚜렷한 특징은 입법이유가 상세하지 않다는 점이다. 그에 따른 부작용은 법률 해석에서 역사적 해석이 거의 불가능한 것이다. 역사적 해석은 조문을 둘러싼 논란을 설득력 있게 해소하는 하나의 방도인데, 우리의 경우 이미 중요한 해석의 방도 하나가 제 기능을 하지 못한다고 할 수 있으며, 이 점이 합리적이고 설득력이 제고된 도그마틱의 전개를 어렵게 한다. 상세한 입법이유가 제시되지 않은 상황에서 제대로 된 법률본문의 구성을 기대하기 힘들다. 법학의 중심이 소송이 아닌 입법으로 옮겨가지 않는 한, 근본적인 변화는 불가능하다.
- 11) 목적규정은 그 법령의 입법 목적을 간결하고 명확하게 요약한 문장을 말한다. 목적규정은 그 법령이 달성하려는 목적 등을 밝혀 일반국민이 입법 목적이나 입법취지를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것이다. 목적규정은 법령의 개별 조문에 대한 해석을 하는 경우 그 법령의 해석지침을 제시하는 역할을 한다. 즉, 목적규정은 그 법령의 입법취지를 명확히 밝혀 그 법령의 각 조문을 해석하고 집행할 때 그 법령의 개별 조문의 구체적인 의미를 입법적으로 명확히 하는 입법적 해석의 기능을 한다. 법제처, 법령입안심사기준, 2020, 47면.

세 가지로 설정한다: i) 인간중심적이고 신뢰할만한 인공지능의 도입, ii) 인공지능시스템에 의한 유해한 영향으로부터 건강, 안전, 기본권, 민주주의, 법치국가적 상태와 환경에 대한 고도의 보호, iii) 혁신의 증진.

Ⅲ. 인공지능법의 적용영역의 변화

1. 인공지능에 관한 새로운 개념정의

의회법안은 인공지능시스템에 관한 새로이 개념정의를 통해 사물적 적용영역과 관련해서 이사회법안과 비교해서 새로운 중요한 변화를 강구하였다. 의회법안 제3조 제1항 제1호에서 인공지능시스템을, ‘다양한 정도의 자율’(Autonomie)로 가동할 수 있으며 명시적·묵시적 목표를 위하여 –물리적이거나 가상적인 주위환경에 영향을 미치는- 예측, 권고나 결정과 같은 결론을 제시할 수 있게 구상되어 있는 기계기반의 시스템’(maschinengestütztes System)으로 정의하고 있다. 그런데 이사회법안(제3조 제1호)의 경우 인공지능시스템은 다음의 두 가지 점을 갖춘 소프트웨어를 의미한다: i) 인공지능법(명령)안 부속서(Anhang) I 에 표시된 하나나 여러 기술이나 구상으로써 개발된 것, ii) 사람이 정한 일련의 목표와 관련해서 내용, 예측, 권고나 결정과 같이 상호작용하는 주위환경에 영향을 미칠 수 있는 것.¹²⁾

인공지능에 관한 양법안의 개념정의를 비교하면, 먼저 EU의회는 더 높은 법적 안정성·일치화·일반적 수용의 달성을 목표로 하여(‘제안이유-6(6)’), OECD의 인공지능지침과¹³⁾ 일치시켰다. 이사회법안과 비교해서 세부적으로 다음의 두 가지 다른 점이 매우 중요하다: i) 인공지능시스템은 다양한 수준의 자율을 나타내야 한다는 점, ii) 이사회법안에 규정된 –다양한 인공지능의 기술과 착안점을 통해 개념정의를 보완하는- ‘부속서(Anhang) I’이 삭제되었다는 점.

의회법안에서 새로이 추가된 자율개념(Autonomiebegriff)은 “인공지능시스템은 적어도 어느 정도로 인간적 통제 없이 가동하여야 하고, 인간의 개입 없이 작동할 수 있어

12) 명령안 제3조 제1호에 대한 부속서 I 은 딥러닝을 포함한 기계학습을, 나아가 전문가시스템을 포함한 지식기반의 착안점 및 통계적 착안점, 탐색방법론과 최적화방법론을 나열한다.

13) OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449, 22.05. 2019, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>. 마지막 방문: 2024.2.4. 이에 의하면, 인공지능시스템은 “사람이 정의한 일정한 목표를 위해, 실제의 또는 가상의 환경에 영향을 미치는 예측, 권고 또는 결정을 하는 기계기반의 시스템(ein maschinenbasiertes System)이고, 다양한 수준의 자율성을 갖출 수 있다.

야 한다.”는 것을 의미한다(‘제안이유-6’). 종래 이사회법안이 인공지능시스템에 대해 전래적인 비지능형 소프트웨어는 물론, 가령 엑셀 스프레드 시트에서의 자동화된 프로세스까지도 포함하여, 인공지능시스템의 개념을 부적절하게 확장시켰다고 비판이 가해졌기에,¹⁴⁾ 의회법안은 이사회법안의 ‘부속서 I’을 삭제하였다. 그렇지만 새로운 개념정의에 의하더라도 단순한 소프트웨어 애플리케이션(Softwareanwendungen) 역시 부분적으로 어느 정도로 자율적으로 가동할 수 있어서, 바람직하지 않게도 규율대상인 인공지능시스템에 들어갈 수 있다. 이에 Feuerstack/Becker/Hertz는 자율성의 수준을 언급하고 이사회법안 ‘부속서 I’을 삭제함으로써, 법률의 사물적 적용분야가 실제로 충분하게 제한되었는지 의문을 제기하였다.¹⁵⁾

2. 인적 규율대상의 확대

이사회법안은 이 관련자를 전혀 상정하지 않아 그의 권리를 전혀 담고 있지 않은 점이 비판되었다.¹⁶⁾ 이런 비판을 수용하여, 이사회법안은 제28조의 기왕의 표제(판매자, 수입자, 이용자나 기타 제3자의 의무)부터 변경하고(제공자, 판매자, 수입자, 운영자나 다른 제3자의 가치창출의 사슬(KI-Wertschöpfungskette)에 따른 책임성), 인적 규율대상을 인공지능의 제공자와 운영자까지 확대하였다. 관련인으로서¹⁷⁾ 제3자가 인적 규율대상에 포함된 데 맞춰 의회법안은 바람직하게도 관련인의 일련의 권리를¹⁸⁾ 규정한다. 그러나 의회법안은 관련인의 의무는 달리 언급하지 않는다.

3. 오픈소스 소프트웨어의 적용예외

이사회법안이 오픈소스 소프트웨어(OSS)에¹⁹⁾ 관해 명시적인 예외를 두지 않은 것을

14) Ebert/Spiecker gen. Döhmman, Der Kommissionsentwurf für eine KI-Verordnung der EU NVwZ 2021, S.1188(1189); Smuha, How the EU Can Achieve Legally Trustworthy AI, 2021, 14f; Spindler, Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung zur Regulierung der Künstlichen Intelligenz(KI-VO-E) CR 2021, S.361(373); Bomhard/Merkle, Europäische KI-Verordnung, RDt 2021, S.276(278).

15) Feuerstack/Becker/Hertz, a.a.O., S.421(424).

16) Smuha, a.a.O., S.14(50ff.)

17) 의회법안 제3조 제1항 제8호의a에 의하면, 인공지능시스템의 지배를 받거나 달리 그것과 관련되는 모든 자연인이나 그 집단이 관련인이 된다.

18) 내국 감독청에 항변하거나 행정심판을 제기할 권리(법안 제68조의b), 인공지능기반의 결정의 설명에 관한 권리(법안 제68조의c) 등.

19) ‘공개소프트웨어’라고 달리 표현되기도 하는 이것은 누구나 검사, 수정 및 개선할 수 있는 소스 코드가 포함된 소프트웨어를 말한다.

두고서, 그로 인해 연구와 혁신에 잠재적으로 부정적 영향을 미칠 수 있다는 비판이 제기되었다.²⁰⁾ 이런 비판을 고려하여 의회법안 제2조 제5항의e에 의해, 오픈소스 소프트웨어(OSS)는 명백히 적용영역에서 제외된다. 다만 오픈소스 소프트웨어(OSS)가 고리스크의 인공지능시스템이나 금지된 인공지능 애플리케이션의 일부가 아니어야 한다. 의회법안 제28조의b에는 기본모델(Basismodelle; foundation models)의 제공자의 의무가 규정되어 있는데, 그에 따른 요청은 기본모델이 오픈소스의 라이언스를 통해 사용되는지 여부에 관계없이 통용된다. 그리하여 기대와는 달리, 오픈소스 소프트웨어(OSS)에 대한 특권부여(Privilegierung)가 작은 애플리케이션 분야에서만 의미를 가진다.

IV. 리스크의 등급과 관련한 변경

의회법안 역시 이사회법안과 마찬가지로 기본적인 리스크기반의²¹⁾ 착안점을 견지하여, 권리와 보호법익(대상)을 위한 리스크 및 그로 인한 규율수준을 다음과 같이 4가지로 나누었다: i) 수용불가한 리스크(inakzeptables Risiko)를 지닌 인공지능의 관행(실행, KI-Praktiken)의 금지, ii) 상세한 규율의 지배(일종의 고강도 규제)를 받는 고리스크의 인공지능시스템, iii) 일정한 투명성요청의 지배(일종의 저강도 규제)를 받을 뿐인 저리스크의 인공지능시스템, iv) 기본모델(Basismodelle). 이사회법안의 기왕의 3등급과는²²⁾ 다르게 의회법안은 새로운 리스크등급의 하나로 기본모델을 추가로 설정하였는데, 여기에는 가령 ChatGPT와²³⁾ 같은 생성형 인공지능모델(generative KI Modelle)이

20) LAION, An Open Letter to the European Parliament Protecting Open Source AI for a Safe, Secure, and Sovereign Digital Future, 2023, abrufbar unter <https://laion.ai/notes/letter-to-the-eu-parliament/>; Ebers, RD 2021, 528, 529; Spindler, a.a.O., S.361(363).

21) 법안에서 위험(danger)이란 용어를 사용하지 않고 리스크(risk)란 용어를 사용한 뜻을 제대로 헤아려야 한다. ‘고리스크’(hohes Risiko; high-risk)에 관한 바른 이해가 필요하다. 이는 발생의 ‘개연성이 인정되는 상태’(wahrscheinlich, likely, probably)인 위험(danger)의 상황에 가까운 ‘고도의 가능성’(highly possible)이 있는 상황을 의미한다.

22) i) 수용불가 리스크(inakzeptables Risiko), ii) 고리스크(hohes Risiko), iii) 저리스크와 최소리스크(geringes sowie minimales Risiko). 수용불가 리스크의 인공지능에 대해 법안은 하나의 예외를 제외하고는 전면 금지하고, 고리스크 인공지능만을 위한 강행규율을 담고 있다. 반면에 저리스크와 최소리스크의 인공지능의 경우에는 법안의 요구사항을 수용하는 것은 임의적이다.

23) 이것은 미국의 인공지능 연구소인 OpenAI가 개발한 프로토타입 대화형 인공지능 챗봇이다. ChatGPT는 Generative Pre-trained Transformer(GPT)와 Chat의 합성어이다. 다른 챗봇들과 달리, ChatGPT는 주고받은 대화와 대화의 문맥을 기억할 수 있으며, 모종의 보고서나 실제로 작동하는 파이썬 코드를 비롯한 사람이 한 것과 같은 상세하고 논리적인 글을 만들어 낼 수 있다(위키피디아).

들어간다.

1. 금지된 인공지능시스템의 리스트 수정

법안 제5조에 담겨진, 금지된 실행(Praktiken)이 수정되고 보완되었다. 이사회법안에서는 중대한 범죄행위를 추적하기 위해서는 예외의 허용을 규정하였는데(제5조 제1항 제d호),²⁴⁾ 의회법안에서는 公衆이 접근할 수 있는 공간에서 생체인식-원격인식시스템을 사용하는 것은 예외 없이 금지된다. 즉, 이사회법안에서 인정된 예외가능성이 의회 법안에서는 완전히 삭제된 것이다. 이처럼 EU법이 회원국의 국내안보 목적의 인공지능시스템의 사용을 직접적으로 규율한 것과 관련해서 두 가지의 물음이 제기된다. 즉, 이런 예외의 불허가 과도한 금지에 해당하는지 여부와 유럽연합이 자신의 권한을 유월하였는지 여부이다.²⁵⁾

잠재의식에 영향을 주는 기술을 사용하는 인공지능시스템의 금지와 관련해서도 후술하듯이 중대한 수정이 있다(의회법안 제5조). 이사회법안이 사회적 점수제(Social Scoring)를 목적으로 한 인공지능시스템을 공적 영역에서만 금지한 것이 차별금지의 차원에서 비판되었는데,²⁶⁾ 의회법안은 이런 비판을 반영하여 국가적 주체에 국한하지 않고 그런 용도의 인공지능시스템을 전면 금지하였다. 자연인의 재범리스크를 평가하기 위한 인공지능시스템 즉, 재범리스크예측시스템은²⁷⁾ 통계적 상호관계와 일반화를 바탕으로 하여 결정을 내린다. 여기서 인권적으로 윤리적으로 제기되는 복잡한 물음이 징역형과 같은 심대한 기본권적 개입을 가져다주는 결정이 인공지능시스템에 맡기는 것이 허용되는지 여부이다. 이사회법안의 입장과는²⁸⁾ 달리, EU의회는 이런 인공지능시스템의 사용

24) 공중이 접근가능한 공간에서 형사소추목적으로 실시간 원격 생체인식(식별)시스템을 이용하는 것. 다만 이하의 목적과 관련해서 그것이 무조건 필요하면 그러하지 아니한다: i) 범죄행위로 인한 일정한 잠재적 희생자나 실종 어린이에 대한 의도적인 수색의 경우, ii) 자연인의 생명이나 신체적 온전성(Unversehrtheit)에 대한 구체적이고, 중대하며 직접적인 위협이나 테러 공격을 사전에 저지하는 경우, iii) Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates(Rahmenbeschluss des Rates v. 13.6.2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten) 제2조 제2항상의 범죄의 -동범에 의하면 관련 회원국에서 적어도 최장 3년의 자유형이나 구금에 처해지는- 행위자나 혐의자를 인식(인지), 추적, 식별이나 소추하는 경우.

25) Martini, Gesichtserkennung im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, NVwZ Extra 1-2/2022, S.1(6).

26) Ebert/Spiecker gen. Döhmman, a,a,O., S.1188(1189).

27) 이런 예측치안(Predictive Policing) 시스템을 대표하는 것이 미국의 ‘노스포인트’社가 개발한 빅데이터 분석 인공지능인 ‘COMPAS’이다. Feuerstack, Menschenrechtliche Vorgaben an die Transparenz KI-basierter Entscheidungen und deren Berücksichtigung in bestehenden Regulierungsansätzen, Ordnung der Wissenschaft, 2022, S.167(170f.).

을 전면 금지하였다(제5조 제1항 제d호의a).²⁹⁾

2. 고리스크의 인공지능시스템에 대한 요청의 수정

의회법안은 고리스크 시스템의 적용영역을 분명히 한다. ‘부속서 III’에 적시된 인공지능 시스템은, 그것이 사람의 건강, 안전이나 기본권을 위한 현저한(중대한) 리스크에 해당해야만 고리스크시스템으로 여겨진다. 이를 넘어서 의회법안 제10조 제2항 제f호는 이사회 법안의 운영부분(im operativen Teil)에서 여태 언급되지 않은 차별위험(Diskriminierungsgefahr)을 지적한다. 더해서 고리스크의 인공지능시스템은 가능한 왜곡과 차별리스크의 차원에서 조사되어야 할 뿐만 아니라, 의회법안 제10조 제2항 제f호에 따라 편견을 줄이고 피하기 위한 조치 역시 취해야 한다. 또한 인적 데이터를 보호하기 위한 분명한 요청도 담겨 있다.³⁰⁾ 고리스크 인공지능시스템에 관한 투명성과 해석가능성에 대한 핵심적 요청을 담은 제13조 역시 명료하게 표현되어 있으며 수정되었다. 의회법안 제14조가 감독자가 합당한 인공지능 지식을 사용해야 한다는 의무를 지움으로써, 효과적인 인적 감독의 필요성이 보완되게 하였다.

3. 기본모델(Basismodelle)과 생성형 인공지능을 위한 규칙

의회법안은 새로운 리스크의 범주로 소위 기본모델을 도입한다. 의회법안 제3조 제1항 제1호의c에 따라 기본모델은 광범한 데이터베이스에서 트레이닝이 되었고, 일반적인 출력(Ausgabe)에 맞춰 설계되어 있으며, 구분된 임무의 광범한 스펙트럼에 상응할 수 있는 인공지능시스템의 모델(KI Systemmodell)을 의미한다. 소위 범용목적의 인공지능 시스템이란 광범한 스펙트럼의 애플리케이션에서 사용되고 이에 조응할 수 있는 (의도적으로 특별히 그것을 위하여 개발되지 않았던) 인공지능시스템으로 정의되는데, 이것 역시 기본모델에 포함된다. 기본모델의 그 밖의 하위범주가 생성형 인공지능시스템이

28) 이사회법안 제6조 제2항 부속서 III 제6호에 의해 예측치안(predictive policing)이나 범죄발견을 위한 인공지능시스템은 고리스크 인공지능시스템에 해당한다.

29) 그런데 Feuerstack/Becker/Hertz는 관련자가 그 결정에 대해 대처할 수 있는 인공지능 기반의 결정을 위한 합당한 해명과 이유제시의 메커니즘이 존재하는 한, 이런 인공지능시스템을 고리스크의 인공지능시스템(Hochrisiko-KI-Systeme)으로 분류하는 것이 기본권적으로 합당할 것이라고 한다. Feuerstack/Becker/Hertz, a.a.O., S.421(425).

30) 데이터(Data)와 정보(Information)의 차이를 살펴볼 필요가 있다. 정보는 의미론적으로 인식된 데이터이고, 데이터는 이런 정보의 운반자(Träger von Informationen)라 할 수 있다. 데이터는 커뮤니케이션에서의 사용을 위한 원료가 된다. W. Hoffmann-Riem, Die digitale Transformation, in: Unger/Unger-Stenberg(Hrsg.), Demokratie und künstliche Intelligenz, 2019, S.129(136).

다. 의회법안 제28조의b(기본모델제공자의 의무) 제4항에서 생성형 인공지능(generative KI) 시스템은 다양한 정도의 자율성을 지님으로써 복잡한 텍스트, 그림, 음성데이터나 화상데이터와 같은 내용을 생성하는 인공지능시스템으로 정의 내려져 있다. 이에 속할 수 있는 대표적인 것이 ChatGPT이다.

기본모델의 규율시스템은 高리스크 인공지능시스템의 그것보다는³¹⁾ 덜 엄격하다. 기본모델에서 제공자는 다음의 의무를 진다: i) 시장개입 전에 리스크의 평가와 축소를 위한 조치를 취할 것, ii) 사용된 데이터셋을³²⁾ 적합한 데이터 거버넌스의 절차(Daten Governance-Verfahren)의 지배를 받게 할 것, iii) 합당한 급부수준·예측가능성·해석가능성·수정가능성을 보장할 것, iv) 에너지소비를 축소할 것. 생성형 인공지능시스템의 경우에는 제공자는 추가로 다음의 의무를 진다: i) 운영자에게 내용이 언제 인공지능에 의해 생성하는지를 알려줄 것. ii) 합당한 교육조치와 디자인조치를 취할 것. iii) 생성된 합성된 내용이 적법하다는 점을 보장할 것, iv) 저작권법적으로 보호되는 데이터가 모델을 트레이닝하기 위하여 사용되는지 여부와 그 정도를 밝힐 것. 한편 제공자가 오픈소스 소프트웨어(OSS)로서의 기본모델을 사용할 수 있게 하더라도, 이상의 모든 의무는 명시적으로 통용된다. 그런데 기본모델은 ‘CE-표시’를 담을 필요가 없으며, 또한 그것은 법안 제3편 제2장과 제16조부터 제28조까지와 제29조의 엄격한 상세한 요청에 부합할 필요가 없다. 제계 대표자들은 높은 금융비용과 연계될 수 있는 점을 들어 의회법안 제28조의b 제2항에 따른 리스크식별·축소·관리의 의무를 강하게 비판한다.³³⁾ 막강한 대기업에 비해 중소기업 및 스타트업은 준수비용(Compliance-Aufwand)이 높아서 불이익을 받을 수 있다. 그런데 의회법안 제28조의b 제2항상의 제공자의 리스크식별·축소의 의무가 실제로 전환가능한지 여부의 물음이 제기된다.³⁴⁾

31) 高리스크 인공지능시스템에 대한 요구의 차원에서 리스크에 따라 분류된 리스크관리시스템, 품질관리시스템, 투명성의무와 공표의무를 도입하였다.

32) 데이터셋은 여러 개의 정보를 담고 있는 데이터를 추상적인 하나의 정보 단위로 간주하고, 이러한 정보 단위인 데이터를 여러 개 모아놓은 집합을 의미한다(정보통신용어사전).

33) Herwatz/Meiritz, Wie viel KI-Regulierung kann sich Europa leisten?, Handelsblatt, 28.06.2023, <https://www.handelsblatt.com/politik/international/kuenstliche-intelligenz-wie-viel-ki-regulierungkann-sich-europa-leisten/29220470.html>. 독일 정부 역시 비판적이어서 기본모델보다는 범용목적의 인공지능시스템(KI-Systemen mit generellem Verwendungszweck; general purpose AI systems)을 제한한다.

Vgl. Wieduwilt, Scholz und Macron träumen von EU-ChatGPT, FAZ, 03.10.2023, <https://www.faz.net/pro/d-economy/kuenstliche-intelligenz/scholz-und-macrontraeumen-von-eu-chatgpt-19217062.html>.

34) Spies, ChatGPT & Co. – Keine Insellösungen, MMR 2023, S.469(470).

V. 인공지능기반의 결정의 불투명성을 제고하기 위한 변경

1. 인공지능시스템의 불투명성과 설명가능성의 결여 문제

그 특성으로 사람을 평가하는 결정의 과정에 인공지능시스템을 도입할 경우, 인공지능시스템의 불투명성과 설명가능성의 결여가 더욱더 중요해진다.³⁵⁾ 인공지능시스템에서 주어진 입력(Input)에서 어떻게 일정한 출력(Output)에 도달하는지가 종종 전혀 확인될 수 없거나 극히 고비용이 들어야 비로소 확인될 수 있다.³⁶⁾ 프로그래머와 전문가들도 시스템에서 구체적인 출력이 생성되는 이유와 다른 결론이 생성되지 않는 이유를 사전에 정할 수 없다. 그리하여 인공지능시스템이 도입되어 내린 결정에서 인공지능시스템에 의해 정해진 부분은 결코 설명될 수가 없다. 불투명성의 정도는 인공지능시스템에 따라, 개별적 맥락에 따라 그리고 참여한 행위주체에 따라 바뀔 수 있다. 딥러닝이나 서포트 벡터 머신(SVM)³⁷⁾ 바탕을 둔 여러 인공지능시스템은 그 누구도 결정발견의 과정을 납득할 수 없게 복잡하다. 그런 경우 제조자와 인공지능전문가 역시 개개의 출력력을 위한 원인을 분명하게 결정하고 설명할 수가 없다(설명가능성과 이해가능성의 결여). 인공지능 기반의 결정이 관련자와 운영자에 대해 불투명한 주된 원인은, 시스템의 제공자나 운영자가 결정의 매개변수에 관한 비밀을 준수하는 데 있다.³⁸⁾ 종종 영업비밀로서 이런 정보의 보호가 주장되는데, 이를 넘어서 자세한 기능방식 역시 관련인에 대해 비밀준수가 요구될 것이다.

2. 평가규준으로서의 절차적 권리

인공지능기반의 결정의 관련인들이 효과적으로 자신을 방어할 수 없으면, 불투명성

³⁵⁾ Feuerstack, Künstliche Intelligenz und internationale Menschenrechte, ZfDR 2023, S.184(198f.).

³⁶⁾ Kment/Borchert, Künstliche Intelligenz und Algorithmen in der Rechtsanwendung, 2022, 43; Wischmeyer, Regulierung intelligenter Systeme, AöR 143(2018), S1(46); Feuerstack, ZfDR 2023, 184, 198.

³⁷⁾ SVM(Support Vector Machines)은 기계학습의 분야 중 하나로 패턴 인식, 자료 분석을 위한 지도 학습 모델이며, 주로 분류와 회귀 분석을 위해 사용한다. 두 카테고리 중 어느 하나에 속한 데이터의 집합이 주어졌을 때, SVM 알고리즘은 주어진 데이터 집합을 바탕으로 하여 새로운 데이터가 어느 카테고리에 속할지 판단하는 비확률적 이진 선형 분류 모델을 만든다. 만들어진 분류 모델은 데이터가 사상된 공간에서 경계로 표현되는데 SVM 알고리즘은 그 중 가장 큰 폭을 가진 경계를 찾는 알고리즘이다. SVM은 선형 분류와 더불어 비선형 분류에서도 사용될 수 있다(위키피디아). Vgl. Bathaee, Harvard Journal of Law & Technology 31(2018), 889, 903ff.

³⁸⁾ Vgl. Wischmeyer, a.a.O., S.1(48).

과 설명가능성의 결여는 기본권과 인권의 관점에서 문제가 있다. 그래서 가령 차별이나 기타의 정신적 손해가 증명되지 않을 수 있다.³⁹⁾ 이것은 특히 프로파일링-결정과 관련이 있다. 이런 결정의 경우 인공지능시스템을 이용하여 인적 데이터에 의거하여 사람에 대해 어떤 결정이 내려져서, 차별과 불허된 데이터처리와 같은 일정한 정신적 권리침해의 리스크가 존재하고, 극단적인 상황에서는 정당하지 않은 자유박탈의 위험이 있다. 가령 국가가 형사소송에서 범죄예방과 범죄규명을 위하여 혹은 가령 실업수당과 같은 일정한 급부의 보장을 위하여 인공지능시스템을 사용하는 경우가 그렇다. 다른 한편 가령 민간이 신용도의 결정이나 금융지원의 과정에 인공지능시스템을 이용하는 것도 포함될 수 있다.⁴⁰⁾

불투명성과 설명가능성의 결여와 관련한 기준은 맥락에 따라서 효과적인 쟁송에 관한 권리, 무기대등(Waffengleichheit)에 관한 권리 및 실체적인 인권법적 보장, 차별받지 않은 권리로부터 생겨난다. 이들 권리에 관한 EU법상의 근거는 한편으로는 국제적인 인권협약, 국제법적으로 구속적인 인권협약에,⁴¹⁾ 다른 한편으로는 유럽인권협약(EMRK)과 같은 지역적 협정(Abkommen)과⁴²⁾ EU기본권헌장(GRC)과 (독일) 기본법과 같은 헌법에⁴³⁾ 있다. 국가적 행위주체의 결정에 대해서는 엄격한 이유제시의 의무가 통용되는데, 이를 통해 결정의 절차적 실질적 심사가 가능하게 된다. 결정의 발견에서 인공지능시스템이 사용되더라도 이유제시의 의무는 통용된다. 왜냐하면 그렇지 않으면 결정주체가 자신의 결정을 간단히 인공지능시스템에 맡길 수 있을 것이고 그러면 더 이상 설명할 책임을 지지 않을 것이기 때문이다. 인공지능기반의 결정에서 이유제시는 관련 인적 입력데이터, 구체적인 경우에서의 그것의 가중치(Gewichtung), 이런 비교집단에 속한 개연성값(Wahrscheinlichkeitswerte, 수치)에 관한 구체적인 정보를 공개하는 식으로 행해진다.

³⁹⁾ Feuerstack, OdW 2022, 167, 170.

⁴⁰⁾ 그런데 이런 민간 결정주체와 관련자 사이에 상하관계, 힘·정보의 비대칭의 관계, 일방적인 의존관계가 존재하는 것이 이런 분야의 특징으로 확인된다. 이런 민간분야에서 결정주체에게 유리한 결정에 관련인이 강하게 의존하기 때문에, 결정주체가 사회적 참여에 대해 강력한 권력을 갖는다.

⁴¹⁾ ‘시민의 권리와 정치적 권리에 관한 국제규약’(Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte(IPBPR): International Covenant on Civil and Political Rights v. 19.12.1966, 999 UNTS 171).

⁴²⁾ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms v. 4.11.1950, ETS No.005.

⁴³⁾ 여기서 주목할 것이 독일의 경우 절차적 권리를 기본권에 바탕을 두고 설정하는데, 우리의 경우 개별 기본권의 차원이 아니라 적법절차의 원칙에서 바라보는데, 그 결과 현행 법상황을 절차적 정의에 맞췄서 격상하려는 움직임이 미약하다. 일반원칙으로의 도피하는 것이라는 비판이 제기될 수 있다.

국가와 유사한 상하관계에서 민간이 결정의 발견에 인공지능시스템을 사용하는 경우, 私人은 원칙적으로 직접적으로 인권과 기본권에 구속되지 않는다. 그러나 인공지능 기반의 결정에 대해 관련인이 효과적인 재송을 강구할 수 있도록 하기 위하여, 국가는 기본권적 보호의무에 의거해서 적합한 투명성의 메커니즘을 만들어야 한다.⁴⁴⁾ 이런 상황에서도 관련인에 대해 이유제시의 의무를 만드는 것이 고려되지만 강제적이지는 않다. 여기서 관련인을 위한 증명완화, 일정한 기록의무와 공개의무 역시 생각할 수 있다. 그러나 기본권적 보호의무를 행사하는 데 있어서 국가는 엄격히 비례원칙(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz)에 구속된다. 왜냐하면 기업의 권리, 가령 사적자치 및 - 경우에 따라서는- 영업비밀의 보호를 충분히 고려해야 하기 때문이다. 관련인에 대해 국가와 유사적인 상하관계에서 행동하는 민간주체만이 의무를 지는 경우에는, 있을 법한 투명성의 메커니즘이나 이유제시의 의무와 관련하여, 그것은 비례적이라 평가될 수 있을 것이다.⁴⁵⁾ 관련인이 일정한 범위에서의 그에게 유리한 결정에 의존하는 곳에서만 인권법상으로 강행적으로 보호되어야 할 투명성에 관한 이익이 존재한다.

3. 의회법안에서의 인공지능시스템의 투명성과 설명가능성

이사회법안은 기본권적으로 인권적으로 바탕을 둔, 인공지능 기반의 결정에서의 합당한 투명성 메커니즘의 필수성을 간과하였다. 인공지능시스템을 투명하고 해석가능하게 만들 의무를 이사회법안 제13조가 규정하고 있지만, 여전히 세부적 내용이 불명확하며, 운영자가 시스템을 상당히하게 이용하고 제어할 수 있는 목적도 추구한다고 비판이 제기된다.⁴⁶⁾ 자신과 관련이 있는 인공지능기반의 결정의 이유를 알아야 할 권리가 결여되어 있으며, 그런 결정과 관련해서 증명완화나 투명성메커니즘을 위한 규칙도 결여되어 있다. 더군다나 이사회법안 제52조상의 투명성의무(Transparenzpflicht)는 인공지능시스템의 사용 여부가 밝혀져야 하는 것과 전적으로 관련이 있으며, 또한 그 투명성의무는 특별한 조작하는 특성을 지닌 소수의 인공지능시스템에만 국한한다. 투명성·이유제시·설명에 관한 권리가 투명성의무로부터 생겨나지는 않는 것이 이사회법안 제52조가 지닌 결정적인 문제점이다.

⁴⁴⁾ Feuerstack, ZfDR 2023, 184, 189.

⁴⁵⁾ 독일 연방 헌법재판소는 경기장판결(Stadionentscheidung)에서 사회적 참여에 대해 국가와 비슷한 처분권을 지닌 민간기업은 헌법상의 이유제시의무를 진다고 판시하였다(BVerfG, NVwZ 2018, S.813(816)). 준공적인(quasi-öffentlich) 분야에서의 기업에 대해 더 강력하게 의무를 지우는 것은 국제법상으로도 점차 주장된다.

⁴⁶⁾ 동지: Fink/Finck, Reasoned A(I)dministration: explanation requirements in EU law and the automation of public administration, European Law Review 47(2022), S.376(391).

의회법안 제52조(투명성의무)는 이사회법안을 그대로 채용하여 변함이 없지만, 의회법안 제13조(투명성과 정보제공)⁴⁷⁾ 다음과 같이 대거 수정되었다. 고리스크 인공지능 시스템은 제공자와 이용자가 시스템의 작동방식을 충분히 이해하게 구상되어 있어야 한다. 이용자와 제공자가 제3편 제3장에서 확정된 해당 의무를 이행할 수 있도록 상당한 투명성이 인공지능시스템의 목적규정에 맞춰 보장된다. 투명성이란, 인공지능시스템의 결론을 이용자와 제공자가 이해할 수 있도록, 고리스크 인공지능시스템의 출시시점에 일반적으로 인정된 기술수준에 따른 가용수단이 도입된 것을 의미한다. 이용자가 인공지능시스템을 상당히 이해할 수 있어야 한다. 인공지능시스템이 어떻게 기능한지 그리고 어떤 데이터가 처리되었는지를 이용자가 일반적으로 알아서 인공지능시스템에 의해 발해진 결정을 관련인에게 의회법안 제68조의c(개별적 결정발견의 설명에 관한 권리)에 따라 설명할 수 있어야 한다(의회법안 제13조 제1항).

의회법안 제68조의c에 의하면, -운영자가 고리스크 인공지능시스템으로부터의 데이터에 기초하여 발하였고 법적 영향을 가지거나 유사한 종류로 (자신의 견해에 의하면 건강, 안전 기본권, 사회경제적 복지나 다른 권리를 제한하는 방법으로) 그들을 제한하는- 결정과 관련이 있는 사람은, 운영자에 대해 제13조 제1항에 따른 -결과과정에서의 인공지능시스템의 역할에 관해, 발해진 결정의 가장 중요한 매개변수에 관해, 입력데이터에 관해- 명료하고 의미 있는 해명(설명)을 요구할 권리를 가진다. 의회법안은 국가적 행위주체와 비국가적 행위주체를 구별하지 않고 이런 설명의무가 통용되도록 규정하였다.⁴⁸⁾ 이처럼 의회법안이 명문으로 제13조의 의무와 제68조의c의 권리가 맞물리게 한 것(Das Ineinandergreifen)은 긍정적으로 평가를 받는다.⁴⁹⁾

핵심적인 결정매개변수를 공개하는 것은 차별이나 하자 있는 결정을 위한 증빙을 사실상 폭로할 수 있다. 그러나 인공지능 기반의 결정의 불투명성의 문제가 완벽하게 규율되어 있지 않다. 의사회법안 제13조 제1항에 의해 시스템의 결론을 이용자가 합당하게(angemessen) 해석하고 적용할 수 있을 것이 요구되었지만, 그것이 무엇을 의미하는지 그리고 해석가능한 것이 결론 그 자체인지 그것의 성립인지도 불분명하다고 비판되었다.⁵⁰⁾ 사실 의회법안 제13조 제1항이 요구하는 것처럼, 작동방식과 처리데이터에 관한 운영자의 지식 역시 제68조의c에 따른 개개의 매개변수를 설명하기에는 충분하지

47) 명칭에서 이사회법안은 ‘이용자를 위한 투명성과 정보제공’이다.

48) 이 점과 관련해서 대비되는 우리 법제의 상황이 2024.3.15.부터 시행될 「개인정보보호법」 제37조의2에서 ‘자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 등’과 관련해서 「행정기본법」 제20조에 따른 행정청의 자동적 처분이 제외된 점이다. 거대 포털은 사실상 국가에 유사하게 권력을 행사한다는 점에 대한 문제인식이 시급하다.

49) Feuerstack/Becker/Hertz, a.a.O., S.421(430).

50) Feuerstack, OdW 2022, S.167(178).

않다.⁵¹⁾ 의회법안 제68조의c에도 불구하고, 개개의 데이터의 가중치와 개별경우의 결정적인 이유나 일반적으로 동원된 결정규칙만이 관련인에게 통보되어야 하는지 여부는 여전히 불분명하다. 의회법안 제68조의c에 의해 관련인이 차별의 증빙을 증명할 수 있게 되는지 여부도 여전히 의문스럽기에, 명확히 할 필요가 존재한다. 왜냐하면 그렇지 않으면, 제한적 해석으로 인해 관련인의 보호가 인권법적으로 필요한 최소한보다 미달할 위험이 있기 때문이다. 동시에, 의회법안 제13조 제1항에 담겨진 투명성의무(Transparenzpflicht)가 그다지 문제가 없는 인공지능시스템에 대해서도⁵²⁾ 통용되는 식으로 부분적으로 너무 지나치지 않느냐의 물음이 제기된다. 마찬가지로 의회법안 제68조의c에 규정된, 개별적 결정발견의 설명에 관한 권리에 상응한 이유제시의무(Begründungspflicht)는 국가적 행위주체나 국가와 유사한 권력적 지위를 지닌 민간에 국한되지 않는다. 그리하여 이런 이유제시의무가 중소기업 및 스타트업에 대해 과도한 부담인지 아니면 비례적 수준인지 여부 그리고 그것이 EU입법자의 인권적·기본권적·규제적 평가여지의 범위내에 속하는 것인지 여부가 의문스럽다. 그렇지만 의회법안 제68조의c 제2항에 의하면, 설명의무의 예외가 EU법이나 국내법으로부터 생겨나고, 기본권과 기본적 자유가 본질적 핵심에서 여전히 보호되고 그 예외가 민주사회에서의 필수적이고 합당한 수단에 해당하면, 의회법안 제68조의c 제1항이 통용되지 않는다. 즉, 설명의무의 예외가 인정된다. 다만 의회법안 제68조의c 제1항에 따른 설명의무는 관련인에 대해 법적 영향을 미치거나 유사한 방식으로 현저히 제한하는 결정에 대해서만 통용되므로 그 자체로 설명의무에 대해 한계가 설정되어 있다.

의회법안 제68조의c상의 개별적 결정발견의 설명에 관한 권리는 설명가능성을 전제로 한다. 따라서 기술적 이유에서 상응한 설명가능성이 결코 만들어질 수 없는 불투명한 인공지능시스템의 경우 사실상 그 사용이 금지되는 결과가 초래되는데, 이런 금지를 투명성이 꼭 필요한 영역으로 국한하면, 그 자체로 결코 과도하지 않다고 할 수 있다. 그러나 인공지능시스템을 투명하게, 해석가능하게 그리고 이해가능하게 만들, 의회법안 제13조의 의무와는 결코 관련이 없다. 대부분의 경우, 특히 전적으로 물질적 손해만이 임박한 경우에는, 증명의 완화(Beweiserleichterungen)와 인과관계의 추정(Kausalitätsvermutungen)으로 충분하다. 그렇지만 책임법적 차원에 속해야 할 이들 문제는 인공지능법이 아니라, 계획된 인공지능책임의 지침(KI Haftungs-RL)에서⁵³⁾ 규율될 것이다.

51) 의회법안 제68조의c에서 가장 중요한 매개변수(Parameter)의 공개가 아니라 중요한 결정이유의 공개를 요구하는 것이 더 좋았을 것이라고 지적된다. Feuerstack/Becker/Hertz, a.a.O., S.421(431).

52) 결코 인적 데이터를 처리하지 않으며, 사람을 통한 결정의 분야에는 도입되지 않는 인공지능시스템이 이에 해당한다.

53) Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates zur Anpassung der

VI. 연구특권의 분야에서의 변경

인공지능에 관한 규율에 대해 유럽의 연구자들은 환영과 함께 우려도 표한다. 그 우려는 법률(명령)의 형식으로 규율이 인공지능의 연구와 그것을 이용한 연구를 어렵게 하거나 심지어 전혀 불가능하게 만들 것이라는 점이다. 이사회법안에서는 -특히 산업과 긴밀하게 협력하는- 연구자와 기관이 동 법안의 제3조 제1항 제2호에 따른 제공자의 개념에 포함될 위험이 있다. 그리하여 EU기본권헌장(GRC) 제13조상의 학문의 자유(Wissenschaftsfreiheit)에 대한 개입의 문제가 생겨난다.⁵⁴⁾ 의회법안에도 이사회법안상의 제공자(Anbieter) 개념이 수용되었지만, 후술하듯이 학문의 자유에 대해 분명히 이사회법안보다 더 광범하게 특권이 부여되었다.

1. 연구특권의 부여

연구특권의 부여(Forschungsprivilegierung)가 의회법안의 ‘제안이유-2f’에서 처음 언급되어 있다. 이것은 연구·혁신의 촉진 및 연구자유를 유지할 목적으로 언급한다. 그에 맞춰 ‘제안이유- 2f’에 의하면, 오로지 학술연구의 목적을 위하여 개발된 인공지능시스템은 인공지능법의 적용영역에 포함되지 않는다. 따라서 인공지능법은 인공지능시스템의 연구·개발을 위한 학문적 활동에 부정적인 영향을 미치지 않을 것이다. 이밖에 ‘제안이유-12a’에 의하면, 오픈소스 소프트웨어(OSS)에 대한 특권부여가 연구·혁신을 지원하는 데도 이바지할 것이다. 연구증진(Forschungsförderung)을⁵⁵⁾ 목표로 언급하지 않아서 학문의 자유가 제약을 받게 된 이사회법안과 분명한 차이점이 있다.

의회법안의 ‘제안이유-2f’에서 언급된 특권부여가 의회법안 제2조 제5항의d에서 구현되는데, 이에 의하면 인공지능시스템의 연구·시험·개발활동은 인공지능법(명령)의 적용영역에서 제외된다. 이런 제외는 이들 활동이 해당 인공지능시스템이 출시되기 전에 행해진 경우에만 통용된다. 이밖에 기본권이 유지되어야 하고 기타의 EU법이 존중되어야 한다. 의회법안의 제2조 제5항의d상의 특권부여로 인해, 이사회법안보다 더 광범하게 학문의 자유에 대해 특권이 부여된다.⁵⁶⁾ 인적 측면에서 의회법안은 사기업의 연구자들

Vorschriften über über außervertragliche zivilrechtliche Haftung an künstliche Intelligenz COM/2022/496 final

54) Becker, Der Kommissionsentwurf für eine KI-Verordnung – Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit? ZfDR 2023, S.164(173ff.).

55) 유의할 점은 이사회법안에서 혁신적 인공지능시스템의 개발은 스타트업과 중소기업의 행정비용과 전적으로 관련이 있다.

56) 그러나 의회법안의 이런 특권부여는 -인공지능시스템 자체에 대한 연구만이 인공지능시스템

이나 공공기관이나 대학의 연구자들간의 구분과는 무관하다. 특권부여의 대상이 명백히 확대된 것이다. 데이터기본명령(DS-GVO)상으로 포괄적인 연구의 특권부여가 민간 연구자들은 물론 대학이나 공공기관의 연구자들에게도 확대된 것에⁵⁷⁾ 견줘, 의회법안상의 확대 역시 설득력이 있다. 여기서 민간기업체의 연구자나 민간기업 자체가 연구의 자유를 주장할 수 있는지 여부는 결정적으로 대상활동이 학문적 연구의 기준-독립성, 결론개방성(결론미확정성), 학문적 방법론의 선택-에 의거하여 판단되어야 할 것이다.

의회법안 제2조 제5항에 따른 특권부여의 범위는 원칙적으로 충분한 것으로 평가될 수 있다. 연구의 차원을 넘어 인공지능시스템이 실제로 출시되는 경우에는 연구자 역시 인공지능법을 준수해야 한다. 그런데 출시(유통)의 개념이 의회법안에 의해 바뀌지 않았으므로, 연구결과(결론)의 공표를 출시로 분류할 여지가 있다.⁵⁸⁾ 그러나 이런 식의 해석여지는 새로 삽입된 제안이유에 의해 분명히 축소된다. 특히 ‘제안이유-2f’는⁵⁹⁾ 학술친화적(wissenschaftsfreundlich) 해석을 찬동한다.⁶⁰⁾ 전체적으로 ‘제안이유-2f’를 고려하면, 학술적대적 해석(wissenschaftsfeindlich)은 설득력이 없다고 평가된다.⁶¹⁾

그리하여 의회법안은 학술의 자유와 관련한 주요 비판논점을 제거하였다. 의회법안 제5조 제1조의a와 제1조의b에 따라 금지된 행위조작 인공지능시스템의 영역에서는 학술적 특권부여가 이사회법안보다 덜 하다(후술). 의회법안 ‘제안이유-16’에 의하면, 인간-기계의 관계에서 자연인에게 해를 끼칠 인공지능시스템을 사용하지 않는 한, 행위조작 인공지능시스템과 상관관계에서 정당한 목적을 위한 연구는 억제되어서는 아니 될 것이다. 또한 연구계획이 인정된 윤리기준에 부합해야 하고, 관련자 및 그 법률대리인의 명시적 동의를 얻어야 한다. 동의획득의 요청에 의한 예외가 이사회법안과 비교해서 추가적으로 제한되어 있지만, 실은 이런 제한은 정당하게 여겨져야 한다. 그래서 동의는 연구와 상관관계에서 그리고 사람과 상관관계에서 EU법적으로도 국제법적으로도 요구된다고 여겨진다.⁶²⁾ 의회법안 ‘제안이유-16’에 의하면, 손해의 발생에서 조작적 인공지능의 제공자나 운영자의 (손해발생의) 의도(Schädigungsabsicht)가 필수적이지 않다. 비록 의회법안이 적용범위를 축소하여 EU기본권헌장(GRC) 제13조상의 학문의 자유

를 이용한 연구 역시 적용영역에서 제외한- EU각료이사회(Rat)의 제출안과는 거리가 있다.

⁵⁷⁾ Becker, OdW 2022, 103ff.

⁵⁸⁾ Vgl. Becker, ZfDR 2023, 164, 169f.

⁵⁹⁾ 이에 의하면, 인공지능법이 전적으로 연구용으로 개발된 인공지능시스템에 적용될 수 없으며, 학문적 활동에 대해 달리 부정적으로도 영향을 미치지 않을 것이다.

⁶⁰⁾ 원칙적으로 바람직할 만한 것은, 연구를 위한 법적 안정성을 제공하기 위하여 그리고 그런 불명료성에서 생길 수 있는 간접적인 연구장애물을 제거하기 위하여, 연구결과(결론)의 공표와 출시의 경계를 분명히 설정하는 것이다.

⁶¹⁾ Feuerstack/Becker/Hertz, a.a.O., S.421(434).

⁶²⁾ Sprange, Recht und Bioethik, 2012, 82ff.

(Wissenschaftsfreiheit)를 더 제한하는 데도 불구하고 여러 측면에서 긍정적으로 평가된다.⁶³⁾

2. 사회적으로 생태적으로 유익한 연구증진

이상의 연구특권을 부여하는 것 이외에, 의회법안 제54조의a(사회적으로 생태적으로 유익한 결과를 뒷받침하기 위한 인공지능시스템의 연구·개발의 증진)는 유럽연합의 회원국에 대해 인공지능연구의 증진을 요구한다. 혁신증진을 위한 조치에서 스타트업과 중소기업을 목표로 하는 이사회법안에는 비교가능한 규율이 없다. 스타트업과 중소기업과 같은 행위주체들은 의회법안에 의해서도 널리 고려되는데, 혁신증진이 연구증진을 위하여 보완된다. 의회법안에 따르면 인공지능시스템에 대한 모든 연구가 그 자체로 증진할만한 것으로 인정되지 않는다. 의회법안 제54조의a 제1항에 따라, 사회적으로 생태적으로 유익한 결과를 뒷받침하는 인공지능시스템의 연구만이 증진된다. 이 아 이템에 속하는 것이 장애인을 위한 참여가능수단의 제공, 사회경제적 불평등의 제거, 지속가능성·환경의 목표의 이행에 이바지하는 인공지능기반의 해결책을 개발하는 것이다. 의회법안 제54조의a 제1항은 연구증진의 목록이 이에 국한되지 않는다는 점을 명시적으로 규정하고 있다.

사회적으로 생태적으로 유익한 인공지능시스템에 대한 연구와 개발을 증진하기 위하여 의회법안 제54조의a 제1항은 다음과 같은 연구증진 수단을 명시적으로 언급한다: i) 리빙 랩(Living Lab, Reallaboren)에 대한 연구자의 우선 접근, ii) 해당 EU기금에 의한 금융적 장려, iii) 적용에서의 지원, iv) 인공지능법(명령)의 전환. 이밖에 의회법안 제54조의a 제2항에 의하면, 관련한 주주의 참여가능성이 제공되어야 한다. 이런 연구증진 역시 대학에서의 연구자만이 아니라, 민간연구자도 사정거리에 들어간다. 이상의 내용은 - 연구증진 그 자체처럼- 학문의 자유의 관점에서 환영할 만하다고 평가된다.⁶⁴⁾

VII. 조작 인공지능시스템 관련한 변경

1. 조작 인공지능시스템의 금지

인공지능시스템이 불순한 여러 용도로 사용될 수 있는 점을 고려하여 인공지능시스템에 의한 조작은 이미 이사회법안 제5조 제1항 제a호에 의해서 수용불가한 리스크로

⁶³⁾ Feuerstack/Becker/Hertz, a.a.O., S.421(434).

⁶⁴⁾ Feuerstack/Becker/Hertz, a.a.O., S.421(435).

분류되었다.⁶⁵⁾ 즉, 이런저런 사람에 대해 신체적이나 심리적 피해를 유발하거나 유발할 수 있는 식으로 사람의 행위에 본질적으로 영향을 미치기 위하여, 사람의 의식 밖의 잠재의식적 영향미침의 기술을 사용한 인공지능시스템의 출시·운영(가동)·사용은 금지된다. 인공지능에 의한 조작의 위험에 대처하는 데 있어서 의사사회법안 동 규정은 그 단출함과 불명료성이 처음부터 비판되었다.⁶⁶⁾ 의회법안의 변경안은 몇 가지 중요한 보완을 담고 있다.

(1) 금지기술

의회법안상 금지기술에는 사람의 의식밖에서 잠재의식적(*unterschwelligen*; *subliminal*) 영향을 미치는 기술만이 아니라, 고의로 조작하거나 기망(欺罔)하는 기술도 해당한다. 원래의 문구-사람의 의식밖에서 잠재의식적(*unterschwelligen*; *subliminal*) 영향미침-는 불명료성과 지나친 한정성으로 비판을 받았다. 특히 ‘잠재의식적 영향미침’이 인공지능법(명령)안으로 정의되지 않아 문제가 될 수 있지만, 원칙적으로 그것은 주체적으로 지각할 수 있는 인지가능성(*Wahrnehmbarkeit*) 이외에서 정보를 제시하는 식의 모드(방법)를 의미할 수 있다. 그리하여 인지할 수 있게 사람에게 영향을 미치는 기술은 배제될 수 있을 것이다. 더해서 ‘사람의 의식밖에서’(*außerhalb des Bewusstseins einer Person*)⁶⁷⁾라는 부가어는 복잡한 신경과학적, 철학적 물음을 제기한다.⁶⁷⁾

반면 조작(*Manipulation*)의 존재 여부는 영향미침을 지각할 수 있는 인지가능성에 좌우되지 않는다. 조작의 개념은 여러 가지로 정의될 수 있지만, 다음과 같은 점을 그 특징으로 한다: 조작하는 사람이 나쁜 자신의 목표를 달성하기 위하여, -타인의 결정을 알지 못한 상태에서- 타인의 인지상, 정서상의 약점을 활용하고 사람을 도구로 이용하는 식으로 타인의 결정에 대해 고의로 영향을 미치는 것. 가령 어떤 목표를 추구하거나 어떤 결정을 내리고 싶은지를 스스로 결정을 내릴 기회를 관련자가 빼앗긴 상황을 견줄 수 있다. 금연결정의 목표를 달성하기 위하여 알 듯 모를 듯 영향을 미치는 식으로 인공지능시스템을 이용하는 경우 결과적으로 잠재의식적 영향미침에 해당할 수는 있지만, 조작에는 해당할 수 없다. 왜냐하면 관련자가 그 영향미침을 의식하고 스스로

65) 물리적, 심리적 손해를 덧붙일 수 있는 방법으로 사람의 행위에 본질적으로 영향을 미치기 위하여 사람의 의식을 넘어선 잠재의식의 기술이 사용되는 경우.

66) Veale/Borgesius, *Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act*, *Computer Law Review International* 4(2021), 97ff.; Franklin/Ashton/Gorman/Armstrong, *The EU's AI Act needs to address critical manipulation methods*(21.03.2022, OECD.AI), <https://oecd.ai/en/wonk/ai-act-manipulation-methods>(마지막 방문 2023.2.6.)

67) 그리하여 ‘의식’(consciousness)보다는 ‘아는 것(지식)’(knowledge)을 선택할 것을 제안하는 문헌으로 vgl. Boine, *Alenabled Manipulation and EU Law*(01.06.2021), S.1(41).

금연목표를 설정하였기 때문이다. ‘조작’과 ‘기망(Täuschung)’의 개념이 약간 모호하고, 의회법안에서 설명이 없으나, 금지에 포함된 기술과 관련해서 일관된 착안점(einen kohärenteren Ansatz)을 나타낸다. 추가로 중요한 새로운 것이 ‘제안이유-16’에서의 보완인데, 이에 의하면 의회법안 동 규정상의 금지는 인공지능기반의 신경과학의 사용 역시 포함한다. 즉, 뇌활동을 다양한 기술적 방법론과 절차로써 측정할 수 있거나 영향을 미칠 수 있으며 -뇌와 컴퓨터의 인터페이스(Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer)를 통해 수집된 신경데이터를 감시·이용·영향미침을 하기 위하여 사용된- 인공지능시스템에 의해 지원을 받는 기술의 사용이 그것이다. 신경과학의 리스크가 더욱더 주의를 끌지만 기왕의 규제가 불충분하다고 종종 비판되어 왔기에, 의회법안에서 신경과학을 분명히 언급한 것은 이런 기술의 규제를 촉진하는 첫 번째 단계에 해당한다. 그리하여 여기서 금지된 기술과 관련해서 중요한 보완이 마련되었다.⁶⁸⁾

(2) 중대한 손해의 필수성

추가로 의회는 사용기술의 목표 및 효과와 관련한 중요한 변경을 제안하였다. 의회법안 제5조 제1항 제a호에 따라 사용된 기술은, 발하지 않았을 결정을 발하도록 하여 확고한 결정을 발할 사람의 능력을 제한하는 식으로, 자세히 말하면 이런저런 사람이나 사람의 집단에 대해 중대한 손해가 발생하거나 발생할 수 있는 방법으로 사람이나 집단의 행위를 뚜렷하게 왜곡하는 목표나 효과를 가져야 한다.

의회법안의 규정은 두 가지 점에서 이사회법안의 그것과 구분된다. 먼저 개인만이 아니라 사람의 집단도 포함되어서 개별적 불이익만이 아니라, 단체의 차원에서의 부정적인 전개양상도 고려된다. 그리고 손해개념이 확장되어, 가능한 손해가 더 이상 물리적, 심리적 손해에 국한하지 않고 재산상의 손해도 포함될 것이다. 이런 확대는 조작의 리스크를 더 광범하게 대하는 데 이바지할 수 있다. 그러나 손해의 개념을 고수하면서 그것의 중대성을 내세운 변경으로 인해 여전히 물음이 남아 있다. 먼저 여기서의 손해가 무엇을 의미하는지 그리고 언제 손해가 중대한지(erheblich)가 불분명하다.⁶⁹⁾ 그리고 다음과 같은 후속물음도 제기될 수 있다: 우울증과 같은 질병상태에 도달하지 않는 한, 감정의 조작이 손해에 해당하는가? 사회적 네트워크에 의한 정치적 입장의 영향미침이 민주사회의 시민 집단을 위하여 손해를 유발하는가? 단순한 조작이나 기망이 관련자를 위한 손해로 여겨질 수 없는가?

68) 그러나 그때그때의 기술에 관한 자세한 서술은 존재하지 않는다. 그리하여 어떤 기술이 금지에 포함되는지 불확실성이 여전히 존재한다.

69) 이사회법안에서 손해개념이 선택된 것에 대해 손해 여부의 기준을 결정하기가 어렵다고 비판이 제기된다. Vgl. Veale/Borgesius, Computer Law Review International 4(2021), S.97(99).

(3) 실용성에 대한 반론

규정의 실용성의 측면에서 이사회법안은 물론, 변경한 의회법안에 대해서 원칙적인 의문이 존재한다. 의회법안 제5조 제1항 제a호 및 제b호에 따른 금지를 위하여, 특별히 결정적인 것이, 인공지능시스템이 사람의 행위에 영향을 미치고 그래서 중대한 손해를 낳을 수 있는 점이다. 인공지능법의 목표는 추후의 손해를 보전하는 것이 아니라, 일정한 의무를 부과하여 그것을 제지하거나 리스크를 축소하는 것이기 때문이다.⁷⁰⁾ 따라서 의회법안 제5조 제1항 제a호 및 제b호에 따른 금지가 적용되기 위해서는, 영향미침의 의도와 그로부터 비롯된 손해발생의 가능성이 존재해야 한다.⁷¹⁾ 그러나 이런 의도와 손해발생의 가능성이 사전에(ex ante) 어느 정도로 추상적으로 의미 있게 평가될 수 있는지가 문제되는데, 그 어려움은 특히 의회법안 제5조 제1항 제b호의 범위안에서 분명해진다. 이사회법안 동 규정에 의하면, 이런 집단에 속한 사람의 행위에 대해 이런저런 사람에게 물리적, 정신적 손해가 발생하거나 발생할 수 있는 식으로 본질적으로 영향을 미치기 위하여, -연령이나 신체적, 정신적 장애에 의거한 사람의 일정한 집단의 약점이나 보호필요성을 활용하는- 인공지능시스템의 출시·운전(가동)·사용을 금지한다. 의회법안은 여기에 분명한 확장을 제안한다. 신체적, 정신적 손해(피해)에서 중대한 손해(피해)로 확장하는 것 이외에, 특히 집단만이 아니라 개인 역시 포함되게 되었다. 그리고 사람의 보호필요성이나 약점이 일반적인 범주(연령이나 장애)가 아니라, -알려지거나 예측된- 개별적 인격성 징표(individuelle Persönlichkeitsmerkmale) 및 개별적인 사회적, 경제적 사정 및 신체적, 정신적 능력에 의거하여 정해지게 되었다. 이런 것은 취약성(Vulnerabilität)의 다양한 차원에 적합하여야 하고, -모든 임의로운 사람의 약점을 활용하는- 인공지능의 잠재성을 인정하는 확장에 해당한다.⁷²⁾ 따라서 보호필요성이나 약점의 존재를 위하여 개별케이스의 사정이 결정적이고, 사전에 활용의도를 확인하기란 어려운 것 같다. 의회법안처럼 취약성이 개별케이스에 좌우된다고 가정하면, 인공지능시스템의 출시·운전(운영, 가동)이 중요할 때 어떤 요소가 합리적인 방법으로 예상될 것일 수 있는지가 의문스럽다.⁷³⁾

조작하는 인공지능시스템을 수용불가한 리스크로 분류한 것은 규범적으로 공감할 수 있긴 하지만, 이런 금지가 추상적이어서 실제로는 중요하지 않을 우려가 있다. 금지를

70) 이 점에서 인공지능법은 특별한 제품안전법의 일종으로 볼 수도 있다.

71) 잠재적 손해와 관련한 의도는 필요하지 않다.

72) 취약성(Vulnerabilität)과 관련한 비판으로 vgl. Cohen, Regulating Manipulative Artificial Intelligence, SCRIPTed: A Journal of Law, Technology and Society, 20(2023), S.203(227ff.).

73) 시스템이 명백하게 명시적이게 영향미침의 목표를 위하여 프로그래밍되어 있어야 하는 것처럼 보인다. 이런 비판으로 vgl. Ebert/Spiecker gen. Döhmman, NVwZ 2021, 1188.

위하여 결정적인 가늠자대는 기술표준이 발견될 수 있는지 여부, 인공지능시스템에 의한 조작과 활용을 원칙적으로 의미있게 저지할 수 있는지 여부, 그래서 인공지능시스템이 사전에 그런 표준의 준수 차원에서 심사될 수 있는지 여부이다. 사정이 그렇지 않다면, 동 규정의 실효성은 심하게 제한된다. 이런 점은 특히 금지된 인공지능시스템이 - 인공지능법을 보완하고 관련자들에 대해 민사법적 배상책임청구권의 관철을 용이하게 할- 새로운 인공지능책임의 지침(KI Haftungsrichtlinie)에 포함되지 않기 때문에, 각별하게 관련이 있을 것이다. 조작으로 피해를 입은 자가 손쉽게 손실보상을 요구하는 것은 결코 가능하지 않을 것이다.⁷⁴⁾ 따라서 사전에 영향미침의 의도와 손해발생의 가능성을 확인하는 것은 여러 가지 어려움에 봉착하는데, 그 어려움이 규범의 실행성과 효과성을 약화시킬 수 있다.

(4) 금지의 예외

의회법안 제5조 제1항 제a호는 후단에서 이상의 전단의 금지의 예외를 규정한다. 즉, 인정된 치료목적용으로 잠재의식적(unterschwellig) 영향미침의 기술을 이용한 인공지능시스템은 설명 이후에 상대방이나 그 법정 대리인이 명시적으로 동의하면, 금지되지 않는다. 이사회법안과 다른 의회법안의 제안은 차별적 규율을 제공하고, 규범의 실용성을 강화하는 데 적합하다. 불분명하게 규정되어 있긴 해도 규범의 적용영역으로부터의 다른 예외가 광고영역을 위하여 존재한다. ‘제안이유-16’에 의하면, 상업적 맥락에서 가령 광고분야에서의 EU법상으로 일치한 ‘허용된 사무처리’(zulässiges Geschäftsverfahren)는 그 자체로 금지에 반하는 절차로 여겨지지 않아야 한다. 그런 EU법이 특히 불허된 사무관행에 관한 EU지침(Richtlinie 2005/29/EG zu unlauteren Geschäftspraktiken: UGP-Richtlinie)이다. 이에 의하면 -가령 정보에 얻은 결정을 발할 소비자의 능력을 눈에 띄게 제한하고 소비자가 달리 발하지 않았을 사무적 결정을 하도록 하게 위하여(동 지침 제2조의e)- 소비자의 경제행위에 대해 특별히 중대하게 영향을 미치는 것은 금지되어 있다(동 지침 제5조 제2항 제b호). 동 지침은 평균의 소비자 개념으로 작동하므로 항상 비판이 가해지는 마이크로 타겟팅(Microtargeting)⁷⁵⁾처럼, 개인화된 광고실무는 포함되지 않는다.

74) 이 점에서 피해자에게는 조작하는 인공지능 시스템을 도리어 고리스크 인공지능시스템으로 분류하는 것이 금지의 대상으로 하는 것보다는 더 유익할 수 있다.

75) 개인맞춤형 공략(세부공략)이나 그냥 ‘마이크로 타겟팅’이라 표현되는데, 선거에서 주로 쓰이는 홍보의 한 방법이다. 대량의 온라인 데이터를 수집하고 분석하여 개인의 선호도와 성향을 파악한다.

VIII. 감정인식시스템과 관련한 변경

의회법안 제5조 제1항 제a호 및 제b호가 영향미침과 조작으로부터 사람을 보호하는 것을 목적으로 하는데, 의회가 새로이 제안한 제5조 제1항 제c호 및 제d호는 사람의 내면적 삶의 사사로움(die Privatheit des menschlichen „Innenlebens“)을 고려에 넣는다. 이에 의하면, 형사소추, 국경관리, 노동시장, 교육기관의 분야에서 자연인의 감정을 추출하기 위한 인공지능시스템(감정인식시스템, Emotionserkennungssystem)을 출시(유통)·운전(가동, 운영)·사용하는 것은 금지된다.⁷⁶⁾ 이사회법안에서는 그런 인공지능시스템을 단지 형사소추와 이주, 망명과 국경통제에서 이용하는 것만을 고리스크의 인공지능으로 분류되었고,⁷⁷⁾ 그밖에는 단지 이사회법안 제52조 제2항에 따른 투명성의무가 통용된다. 이런 법상황은 불충분하다고 비판되었고, 여러 측면에서 금지될 것이 요구된다.⁷⁸⁾ 의회법안은 이사회법안과 반대의 입장이다. 즉, 의회법안 제5조 제1항 제c호 및 제d호의 금지대상에 들어가지 않는 감정인식시스템은 원칙적으로 고리스크 인공지능시스템으로 분류되어야 한다.⁷⁹⁾

하지만 이사회법안에서의 감정인식시스템에 관한 정의 역시 매우 좁다고 비판되었다.⁸⁰⁾ 그러나 종종 감정인식시스템은 확인(식별, Identifizierung)이 불가능하여 생체데이터로 분류될 수 없는 심리적 데이터를 사용하는데, 이는 중대한 흠결로 비판되어, 생체기반의 데이터(biometriegestützter Daten)을 포함할 것이 요구되었다. 이런 지적에 따라 의회법안 제3조 제1항 제34호는 ‘감정인식시스템’을 ‘자연인의 감정이나 의도를 생체데이터와 생체기반의 데이터를 토대로 확인하거나 도출하는 목적에 이바지하는 인공지능시스템’으로 정의한다. 의회가 새로이 제안한 의회법안 제3조 제1항 제33호a에서는 생체기반의 데이터는 ‘자연인의 신체적, 심리적, 행위관련적 신호를 특별하게 기술적으로 처리하여서 얻어진 데이터’로 정의된다. 주목할만한 점은, 감정, 사고, 정신상태나

76) 개념의 불명료성(Unklarheiten)에 대한 염려에서, ‘감정인식시스템’(Emotionserkennungssystem) 개념을 사용하지 않았다.

77) 의회법안 부속서 III 제1항 제6호b·제7호a.

78) Rostalski/Weiss, Der KI-Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission, ZfDR 2021, S.329(351).

79) 의회법안 부속서 III 제1항 제1호aa).

80) 그것은 이사회법안 제3조 제1항 제34호에서 다음과 같이 정의된다: 자연인의 감정이나 의도를 생체데이터(Biometrische Daten)에 의거하여 확인하거나 도출하는 인공지능시스템. 생체데이터는 의회법안 3조 제33호에서 다음과 같이 정의된다: 얼굴이미지(Gesichtsbilder)나 지문검사의 데이터(daktyloskopische Daten)처럼 -자연인의 분명한 확인(식별)을 가능하게 하거나 입증하는- 자연인의 신체적, 심리적, 행위유형적 특징에 관하여 특별한 기술적 절차로써 획득한 인적 데이터. Siehe auch ErwG 7 KI-VOE, diese Definition steht im Einklang mit der Definition in Art. 4 Nr. 14 DSGVO.

의도, 가령 분명히 하면 사람의 내면적 삶의 많은 측면의 추출이 포함된다. 더해서 기왕의 비판을 수용하고 감정인식으로부터의 보호를 확장하기 위하여, 의회는 감정인식시스템의 적격성평가(Konformitätsbewertung)가 제공자에 의해 행해져서는 아니 되고, 인증부처(기관)의 참여하에 행해져야 하도록 ‘제안이유-64’를 변경하였다.⁸¹⁾

한편 의회가 새로이 제안한 ‘제안이유-26의c’에서 감정인식시스템 금지의 근거로 제한적 신뢰성을 내세우는데, 공감할만하지만, 그것이 유일한 근거가 되는지 의문스럽다. 기술적 진보를 고려한 즉, 감정인식시스템에 관한 신뢰성은 바뀔 수 있을 것이기 때문이다.⁸²⁾

IX. 맺으면서-법익의 보호와 혁신의 증진 사이에 균형을 잡는 입법

EU회원국 전원이 EU의회가 마련한 인공지능법안을 승인함에 따라(2024.2.2.) 조만간 EU인공지능법이 현실화된다. 오늘날 고전적 영토국가의 모습은 강하게 쪼개지고 있다. 공법이 자신의 국내의 영토적 한계를 넘어섰다는 것에서 공법의 탈영토주의화(Entterritorialisierung des Öffentlichen Rechts)는 새삼스럽지 않으며, 개별국가를 넘는 문제를 다루도록 구상된 글로벌 공법의 등장 역시 자연스럽다. EU의회는 기본적으로 EU집행이사회가 2021.4.21.에 마련한 EU인공지능법안을 바탕으로 리스크 기반의 인간중심적 착안점을 원칙적으로 유지하면서, 관련 위원회에서 집중적인 협의한 사항과 이사회법안에 대해 제기된 다양한 비판을 적극적으로 수용하여 이사회법안의 주요 내용을 다수 변경하고 새로운 사항을 추가하였다. 전술한 대로 대표적인 것이 불온한 ‘파우스트의 계약’으로 여겨질 법한 생성형 인공지능애플리케이션의 출현에 대응하여, 새로운 리스크의 범주로서 기본모델을 도입한 것이다.

전체적으로 보아 EU인공지능법안은 나름 인간중심적이고 신뢰할만한 인공지능의 도입을 전제로, 건강 등의 법익·법치국가적 상태·환경에 대한 고도의 보호와 기술혁신의 증진 사이에 균형을 강구한다. EU인공지능법은 인공지능시스템에 관한 글로벌 스탠다드가 될 수 있기에, 우리 법제의 형성에서 좋은 본보기이다. EU인공지능법을 본보기로

81) 전술한 것처럼, 조작하는 인공지능시스템과 관련하여 ‘제안이유-16’에서처럼 신경공학의 특별한 관련성이 지적되지 않은 것은 모순으로 여겨진다고 비판된다. 왜냐하면 이것이 사람의 정신적 상태를 확인하거나 도출하는 데 적합하게 보이기 때문이다. Feuerstack/Becker/Hertz,, a.a.O., S.421(443).

82) 한편 일각에서 제안이유에서 그런 시스템의 도입이 지닌 기본권민감성을 인정하여 잠재적으로 위태롭게 될 기본권(특히 EU기본권헌장 제11조의 언론의 자유에 관한 권리)을 거명하는 것이 바람직하다고 지적한다. Feuerstack/Becker/Hertz,, a.a.O., S.421(444).

삼아 법익의 보호와 혁신의 증진 사이에 균형을 이루는 인공지능법제를 조속히 마련해야 한다.

(논문투고일: 2024. 02. 06, 논문심사일: 2024. 02. 21, 게재확정일: 2024. 02. 22.)

참고문헌

- 김남진, 인공지능(AI)기술과 공법학의 변용, 학술원 통신 제321호, 2020.4.1., 2면 이하.
- 김대인, 세계행정법과 국제기구, 행정법연구 제45호, 2016, 231면 이하.
- 김중권, EU행정법, 2018
- _____, 디지털화에 대한 독일 행정절차법의 대응과 그 시사점, 공법연구 제52집 제1호, 2023.10.31., 339면 이하.
- _____, 인공지능시대에 자동적 처분의 법제도화(「행정기본법」 제20조)에 따른 후속과제, 공법연구 제51집 제1호, 2022.10.30., 311면 이하
- _____, 행정절차법 일부개정령의 주요 내용 및 몇 가지 문제점, 법률신문 제4972호, 2022.3.21.
- _____, 인공지능시대에 자동화에 적합한 입법의 문제, 공법연구 제50집 제3호, 2022.2.28., 189면 이하.
- _____, EU인공지능명령안의 주요 내용과 그 시사점, 헌법재판연구 제8권 제2호, 2021.12.31. 65면 이하.
- _____, 인공지능(지능형) 시스템의 도입을 위한 법적 규율의 문제, 공법학연구 제22권 제1호, 2021.2.28. 263면 이하
- _____, 알고크라시(Algocracy)에서의 민주적 정당화의 문제, 법조 제743호, 2020.10.28. 181면 이하.
- _____, 행정에 인공지능시스템 도입의 공법적 문제점, 법조 제740호, 2020.4.28. 53면 이하
- _____, 인공지능시대에 알고리즘에 의한 행위조종과 가상적 행정행위에 관한 소고, 공법연구 제48집 제3호, 2020.2.28., 287면 이하
- _____, 인공지능시대에 완전자동적 행정행위에 관한 소고, 법조 제723호, 2017.6.28. 146면 이하.
- 류병운, 세계행정법, 행정법연구 제16호, 2006.10., 2231면 이하.
- 박혜성/김법연/권현영, 인공지능 규제에 대한 연구-유럽연합의 입법안을 중심으로-, 공법연구 제49집 제3호, 2021, 349-374.
- 이수환/박소영, 금융분야 AI 가이드라인 도입 추진과 시사점, 국회입법조사처 이슈와논점 제1878호, 2021.10.12.
- 이창휘, 국제행정법의 개념 및 기능에 대한 일 고찰, 공법연구 제31집 제2호, 2002, 401면 이하.

정책자료: 「2023 국내외 AI 규제 및 정책동향 LAWnB IP Exclusive Report」, 톰슨로이터코리아); 「바이든 행정부의 첫 인공지능(AI) 행정명령과 시사점」(이슈브리프 제480호, 2023.11.10., 국가안보전략원).

Becker, Der Kommissionsentwurf für eine KI-Verordnung – Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit? ZfDR 2023, 164ff.

Boine, AI-enabled Manipulation and EU Law(01.06.2021), 1ff.

Becker/Feuerstack, Der neue Entwurf des EU-Parlaments für eine KI-Verordnung, MMR 2024, 22ff.

Cohen, Regulating Manipulative Artificial Intelligence, SCRIPTed: A Journal of Law, Technology and Society, 20(2023), 203ff.

Ebert/Spiecker gen. Döhmnn, Der Kommissionsentwurf für eine KI-Verordnung der EU NVwZ 2021, 1188ff.

Feuerstack/Becker/Hertz, Die Entwürfe des EU-Parlaments und der EU-Kommission für eine KI-Verordnung im Vergleich ZfDR 2023, 421ff.

Feuerstack, Künstliche Intelligenz und internationale Menschenrechte, ZfDR 2023, 184ff.

Feuerstack, Menschenrechtliche Vorgaben an die Transparenz KI-basierter Entscheidungen und deren Berücksichtigung in bestehenden Regulierungsansätzen, Ordnung der Wissenschaft, 2022, 167ff.

Fink/Finck, Reasoned A(I)ministration: explanation requirements in EU law and the automation of public administration, European Law Review 47(2022), 376ff.

LAION, An Open Letter to the European Parliament Protecting Open_Source AI for a Safe, Secure, and Sovereign Digital Future, 2023, abrufbar unter <https://laion.ai/notes/letter-to-theeu-parliament/>; Ebers, RDi 2021,528, 529; Spindler, a.a.O., S.361 (363).

Martini, Gesichtserkennung im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, NVwZ Extra 1-2/2022, 1ff.

Hoffmann-Riem, Die digitale Transformation, in: Unger/Unger-Stenberg(Hrsg.), Demokratie und künstliche Intelligenz, 2019, 129ff.

Smuha, How the EU Can Achieve Legally Trustworthy AI, 2021, 14ff.

Spies, ChatGPT & Co. – Keine Insellösungen, MMR 2023, S.469

Spindler, Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung zur Regulierung der Künstlichen Intelligenz(KI-VO-E) CR 2021, 361ff.

Bomhard/Merkle, Europäische KI-Verordnung, RD 2021, 276ff.

Veale/Borgesius, Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act, Computer Law
Review International 4(2021), 97ff.

Wischmeyer, Regulierung intelligenter Systeme, AöR 143(2018), 1ff.

<Zusammenfassung>

Schwerpunkte des Entwurfs des EU-Parlaments für das KI-Gesetz

— Im Vergleich zum Entwurf des EU-Kommission für das KI-Gesetz —

Kim, Jung-kwon*

Die Entterritorialisierung des öffentlichen Rechts in dem Sinne, dass das öffentliche Recht über seine eigenen nationalen territorialen Grenzen hinausgeht, ist nicht neu. Zudem ist die Entstehung eines globalen öffentlichen Rechts ebenfalls selbstverständlich, das sich mit vielfältigen Fragen befasst, die über einzelne Länder hinausgehen. Der Parlamentsentwurf für eine KI-Verordnung verfolgte grundsätzlich einen risikobasierten, menschenzentrierten Ansatz auf der Grundlage des KI-Verordnungsentwurfs der Europäischen Kommission(Kommissionsentwurf). Dazu nahm der Parlamentsentwurf aktiv verschiedene Kritikpunkte auf und änderte viele wesentliche Inhalte des Kommissionsentwurfs und fügte neue Punkte hinzu. Insgesamt strebt der Parlamentsentwurf einen Ausgleich zwischen Rechtsinteressen wie Gesundheit, nationaler Rechtsstaatlichkeit und einem hohen Schutzniveau für die Umwelt sowie der Förderung technologischer Innovationen an. Dabei setzt die Einführung menschenzentrierter und zuverlässige künstlicher Intelligenz voraus. Da es sich beim EU KI-Gesetz(Verordnung) um einen weltweiten Standard für Systeme der künstlichen Intelligenz handelt, fungiert es als ein gutes Beispiel für die Gestaltung unseres Rechtssystems. Nach dem Vorbild des EU-KI-Gesetzes(Verordnung) muss schnellstmöglich unser Rechtssystem für KI geschaffen werden, das den Schutz rechtlicher Interessen und die Förderung von Innovationen in Einklang bringt.

Schlüsselwörter: Entterritorialisierung des Öffentlichen Rechts, Global Administrative Law, Entwurf des EU-Parlaments für das KI-Gesetz, KI-System, Entwurf des EU—Kommission für das KI-Gesetz, Basismodell(foundation model), generative KI Modelle

* Chung-Ang Uni.